

1503343-17.2020.8.26.0005

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Contravenções Penais

Magistrado: JULIANA NISHINA DE AZEVEDO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional V - São Miguel Paulista

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... pela reincidência, referente ao crime de tráfico de entorpecentes - Gravidade do crime precedente que não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Regime intermediário bem fixado - Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação Criminal 0009069-08.2016.8.26.0451; Relator (a): Rodrigo Pares Andreucci; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional V - São Miguel Paulista

1ª Vara Criminal

Av. Afonso Lopes de Baião nº 1736, São Paulo-SP - cep 08040-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503343-17.2020.8.26.0005 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503343-17.2020.8.26.0005

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Contravenções Penais

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3088831/2020 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA, 14411370 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ADRIANO DE OLIVEIRA BAGLIVO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA NISHINA DE AZEVEDO

Vistos.

Adriano de Oliveira Baglivo, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 50, §3º, "a", da Lei das Contravenções Penais, sob a imputação de que, no dia 28 de outubro de 2020, por volta das 16h:00, no estabelecimento comercial situado na rua Georgina Sá Leite Orcessi, n. 386, São Miguel, neste Município, teria explorado jogo de azar em lugar acessível ao público.

O réu foi citado em 14 de fevereiro de 2022 (fl. 56).

A denúncia foi recebida em audiência realizada em 08 de março de 2022, ocasião em foram ouvidas as testemunhas Samuel de Freitas e Eduardo Xavier dos Santos e, a seguir, tomado o interrogatório do acusado (fls. 58 e 59).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência dos pedidos, aduzindo que a autoria restou comprovada pelos depoimentos colhidos em fase judicial e que o laudo pericial produzido conferiu a materialidade do delito. No que tange à reprimenda, pleiteou a fixação da pena base no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, requereu o reconhecimento da agravante da reincidência. Por fim, salientou a possibilidade de fixação do regime inicial aberto e de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (fls. 63 a 65).

A defesa, a seu turno, preliminarmente, pleiteou a contagem em dobro dos prazos processuais, sob o fundamento de que o benefício deve ser estendido ao convênio

efetuado pela Defensoria Pública . No mérito, pugnou pela absolvição do réu, nos termos do artigo 387, V ou VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de materialidade, já que as máquinas se encontravam desligadas e sem apostadores, estando somente armazenadas no estabelecimento. Subsidiariamente, pleiteou a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ou a imposição de regime inicial aberto (fls. 70 a 73).

É o relatório do necessário. Fundamento nos seguintes termos.

Em interrogatório, o acusado afirmou que existiam, de fato, duas máquinas em seu comércio (uma espécie de adegas), mas não estavam funcionando, visto que desligadas. A testemunha Samuel narrou que receberam denúncia anônima de que, no estabelecimento do réu, existiriam máquinas caça-níqueis. Já no local dos fatos, encontraram o acusado, em uma espécie de adegas, onde localizaram duas máquinas desligadas.

A testemunha Eduardo relatou que, atendendo a uma denúncia, diligenciaram ao local dos fatos, onde flagraram dentro de uma adegas duas máquinas desligadas.

Eis o quadro probatório.

De pronto, a preliminar suscitada pela defesa não comporta acolhimento.

Com efeito, a despeito de exercer múnus público semelhante, o advogado nomeado para assistir a parte por força de convenio mantido entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados não goza do benefício do prazo em dobro concedido pelo artigo 186 do Código de Processo Civil.

Isso porque a referida benesse se aplica exclusivamente ao defensor público ou a quem exerça cargo equivalente, não se estendendo, portanto, ao advogado dativo, já que este não compõe o quadro estatal de assistência judiciária.

Acerca do assunto, confira-se o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECESSO FORENSE. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 220 DO CPC. INAPLICABILIDADE. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL EM DOBRO. DEFENSOR DATIVO.

INEXISTÊNCIA DA PRERROGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não se aplica aos processos criminais o disposto no art. 220 do CPC, regulamentado pela Resolução CNJ n. 244/2016, em razão da especialidade das disposições previstas no art. 798, caput e § 3º, do CPP, motivo pelo qual não há falar em suspensão dos prazos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro.

2. A ocorrência de circunstância que provoque a suspensão ou interrupção dos prazos processuais nos tribunais locais deve ser comprovada no ato da interposição do recurso endereçado ao Superior Tribunal de Justiça.

3. O prazo em dobro somente é concedido ao advogado integrante do quadro da assistência judiciária organizado e mantido pelo Estado, não se aplicando tal benefício aos defensores dativos, aos núcleos de prática jurídica pertencentes às universidades particulares e aos institutos de direito de defesa.

4. Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg no AREsp 1997377/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/03/2022, DJe 22/03/2022) – grifos nossos

À vista disso, incabível a preliminar arguida.

No mérito, a pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade veio provada pela prova pericial (fls. 25 a 30), de cuja análise se colhe a seguinte conclusão: As máquinas examinadas apresentaram-se inoperantes. Porém quando operante, estas funcionavam como equipamento sorteador de resultados, nos quais o ganho ou perda independem de habilidade física ou mental do jogador. Trata-se, portanto, de equipamento tipicamente utilizado para a prática conhecida como Jogo de Azar.” (fl. 30).

Do exame do laudo pericial, constata-se, portanto, que as máquinas encontradas junto ao estabelecimento do réu possibilitavam a prática de jogo de azar, em que presente a álea como elemento determinante para o ganho ou perda pelos jogadores. Não há, portanto, dúvida quanto à idoneidade do objeto para o fim contravençional. Nesse sentido, pontue-se que a contravenção penal prevista no artigo 50 do Decreto-Lei 3.688/1941 consiste na exploração de jogo de azar e não da propriedade da máquina. Dessa forma, a conduta descrita no tipo penal foi efetivamente praticada pelo acusado, já que permitiu a instalação de máquinas destinadas ao jogo

de azar em seu estabelecimento, não cabendo a discussão acerca da propriedade das máquinas.

Tanto o acusado, quanto as testemunhas Samuel e Eduardo foram uníssonos em declara que havia máquinas caça niques no estabelecimento comercial do acusado. Diante disso, observam-se demonstrados todos os elementos do tipo penal objeto da acusação, logrando-se comprovar que o réu estabeleceu jogo de azar, por permitir a instalação de máquinas caça-níqueis em seu estabelecimento, local acessível ao público.

Dispensável para a configuração da contravenção que houvesse apostadores ou a demonstração de efetivas apostas, bastando, como se provou no caso vertente, que estivessem máquinas programadas para jogo de azar acessíveis ao público.

Nesse sentido a jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR (LCP, ART. 50, CAPUT). CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS E NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU QUE TINHA EM SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL MÁQUINA CAÇA-NÍQUEL À DISPOSIÇÃO PARA JOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO". (Apelação Criminal nº 2009.040244-5, de Balneário Camboriú. Rel. Des. Roberto Lucas Pacheco. J. 19.05.2011) grifo nosso

"APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRAVENÇÃO PENAL. CAÇA NÍQUEL CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, CONFIRMANDO QUE O LOCAL ERA DESTINADO A EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR. APREENSÃO DE 21 (VINTE E UMA) MÁQUINAS DE CAÇA-NÍQUEL E ELEVADA QUANTIA EM, DINHEIRO. PROVAS DEMONSTRANDO QUE, DE FATO, AS MÁQUINAS APREENDIDAS ESTAVAM EXPOSTAS E EM PLENO FUNCIONAMENTO, FAVORECENDO O JOGO ILÍCITO. LOCAL ACESSÍVEL AO PÚBLICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NOS TERMOS DA LEI PENAL E LEVANDO-SE EM CONTA A QUANTIDADE DE MÁQUINÁRIO APREENDIDO. APENADO QUE JÁ POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS. INVIÁVEL A CONVERSÃO DO REGIME A ELE APLICADO. TERMO CIRCUNSTANCIADO LAVRADO PELA POLÍCIA MILITAR. NULIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SUAS RAZÕES E FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO". (STF.RE 979730, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 01/08/2016)

No mais, de acordo com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a contravenção penal descrita na demanda é delito de mera conduta, sendo irrelevante se as máquinas estavam desligadas.

Nesse sentido:

"Contravenção de Jogo de Azar (máquinas caça-níqueis) -Materialidade perfeitamente demonstrada - O laudo pericial de fls. 06/141 é claro em dizer que, nas máquinas apreendidas, o ganho independe da habilidade do jogador, caracterizando, pois, jogo de azar - Autoria bem demonstrada - Recorrente que admitiu ser o proprietário do bar e que as máquinas estavam em seu interior - Policial que confirmou a apreensão das máquinas em seu estabelecimento - Fato de as máquinas estarem desligadas que não implica em "ausência de exploração do jogo" - Manobra corriqueira para tentar se eximir da responsabilidade penal - Máquinas em local de acesso ao público e que, para serem manuseadas, bastaria ser ligada na tomada de energia - Recorrente que já se viu envolvido na mesma atividade em outras oportunidades, conhecedor, pois, das consequências da manutenção das máquinas no estabelecimento comercial - Pena que merece reparo - Maus antecedentes que não podem prosperar, eis que a condenação que deu causa ao reconhecimento da majorante transitou em julgado posteriormente aos fatos aqui tratados - Pena que é arbitrada inicialmente em três meses de prisão simples mais o pagamento de dez dias-multa - Reprimenda acrescida em um sexto pela reincidência do acusado (fls. 84), resultando em três meses e quinze dias de prisão simples, mais onze dias-multa - Regime intermediário bem fixado pela reincidência, referente ao crime de tráfico de entorpecentes - Gravidade do crime precedente que não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Regime intermediário bem fixado - Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação Criminal 0009069-08.2016.8.26.0451; Relator (a): Rodrigo Pares Andreucci; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Piracicaba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 19/01/2021; Data de

Registro: 19/01/2021) grifo nosso

APELAÇÃO CRIMINAL - JOGOS DE AZAR (ART. 50, DO DECRETO-LEI Nº 3.668/41. EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS - Sentença absolutória - Recurso ministerial - Pretendida condenação do acusado nos exatos termos da denúncia - Possibilidade - Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstradas - Confissão extrajudicial que vem amparada em outros elementos de convicção amealhados durante a instrução - Depoimento de policiais - Validade - Crime de mera conduta, sendo irrelevante que as máquinas estivessem desligadas e/ou sem dinheiro, já que tais condições não são exigidas pela lei, bastando apenas a destinação do equipamento ao jogo de azar - Sentença reformada - Condenação decretada - Pena fixada no mínimo legal, dada as circunstâncias judiciais favoráveis ao agente - Substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos - Cabimento - Preenchimento dos requisitos legais exigidos no art. 44, do Código Penal. Prescrição - Ocorrência - Reconhecimento ex officio da prescrição da pretensão punitiva estatal - Decurso do interstício temporal entre o recebimento da denúncia e o presente julgamento - Sentença absolutória que não é considerada marco interruptivo do prazo prescricional - Recurso ministerial provido e decretação ex officio da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. (TJSP; Apelação Criminal 0008108-98.2011.8.26.0271; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapevi - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 15/12/2015; Data de Registro: 18/12/2015) grifo nosso

"CRIMINAL - JOGO DE AZAR - ARTIGO 50 DO DECRETO-LEI 3.688/41 - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - AUTORIA DEMONSTRADA PELA ADMISSÃO DO RÉU DE QUE ERA A O PROPRIETÁRIO DO BAR E QUE LÁ HAVIA A MÁQUINA CAÇA-NÍQUEL APREENDIDA - POLICIAL CIVIL QUE FEZ A DILIGÊNCIA E TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA, QUE DISSE PRESTAR SERVIÇOS ESPORÁDICOS NO BAR, CONFIRMARAM A EXISTÊNCIA DA MÁQUINA NO ESTABELECIMENTO - POLICIAL ESCLARECEU QUE A MÁQUINA FICAVA NUM DEPÓSITO E QUE O LOCAL ERA ACESSÍVEL AOS CLIENTES - FATO QUE, POR SI SÓ, FAZ PRESUMIR A EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR PELO RÉU - INVEROSSÍMIL A ALEGAÇÃO DO RÉU, PESSOA EXPERIENTE E QUE JÁ FOI CONDENADA DIVERSAS VEZES PELA MESMA INFRAÇÃO, DE QUE TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO DEIXOU A MÁQUINA EM SEU ESTABELECIMENTO CONTRA SUA VONTADE - EVIDENTE QUE ELA FOI ALI COLOCADA PARA EXPLORAÇÃO DOS JOGOS DE AZAR PELO ACUSADO - IRRELEVANTE QUE, NO MOMENTO DA APREENSÃO, ELA ESTAVA DESLIGADA E SEM DINHEIRO - CONFORME ESCLARECEU O POLICIAL CIVIL, A AÇÃO POLICIAL FOI MOTIVADA POR DENÚNCIA ANÔNIMA DA INFRAÇÃO NO LOCAL DOS FATOS E É MUITO COMUM, EM CASOS COMO ESSE, OS INFRATORES MANTEREM AS MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS DESLIGADAS, LIGANDO-AS SOMENTE QUANDO SÃO USADAS PELOS JOGADORES, PODENDO, INCLUSIVE, SER USADA EXTENSÃO ELÉTRICA PARA QUE SEJA LIGADA EM TOMADA EXISTENTE EM CÔMODO ANEXO - MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELO LAUDO PERICIAL DE FLS. 30/33, O QUAL FOI CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE A MÁQUINA APREENDIDA APRESENTA-SE COMO SORTEADORA ALEATÓRIA DE RESULTADOS E O GANHO OU PERDA INDEPENDEM DE CAPACIDADE FÍSICA OU MENTAL DO AGENTE, O QUE BASTA PARA A COMPROVAÇÃO DE QUE HAVIA EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR NO LOCAL - TIPICIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, EIS QUE NÃO FOI CONCEDIDO O EFEITO SUSPENSIVO NA AÇÃO COM REPERCUSSÃO GERAL A RESPEITO DO TEMA A SER JULGADO PELO C. STF - CORRETA CONDENAÇÃO - RÉU PORTADOR DE PÉSSIMOS ANTECEDENTES (FLS. 44/48) E REINCENTE ESPECÍFICO (FLS. 46) - AUSÊNCIA DE ATENUANTES - PROBLEMAS DE SAÚDE DO RÉU NÃO CONSTITUEM ATENUANTES NEM CAUSAS DE ISENÇÃO DE PENA - PENA FIXADA EM 4 MESES E 2 DIAS DE PRISÃO SIMPLES E 13 DIAS-MULTA - PÉSSIMOS ANTECEDENTES E REINCENTE ESPECÍFICA IMPÕEM A FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA CORPORAL E IMPEDEM A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - AUSÊNCIA DE "BIS IN IDEM" - RÉU NÃO ESTÁ PRESO POR ESTE PROCESSO, NÃO HAVENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER RECONHECIDO - QUESTÃO REFERENTE À VAGA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM REGIME FIXADO E EVENTUAL DIREITO AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR EM RAZÃO DE PROBLEMA DE SAÚDE SÃO MATÉRIAS QUE CABEM AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO IMPROVIDO. ANA CLAUDIA MADEIRA DE OLIVEIRA JUÍZA RELATORA" (TJSP; Apelação Criminal 1514297-16.2018.8.26.0451; Relator (a): Ana Claudia Madeira de Oliveira; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Piracicaba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020) (grifo nosso)

Passa-se, então, à dosimetria da pena.

Analisando-se os antecedentes do acusado (fls. 15/16 e 46/47), observa-se que já ostenta uma condenação criminal transitada em julgado, o que impede a fixação da pena base no mínimo legal.

Trata-se do processo n. 0016826-72.2012.8.26.0005, oriundo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, pelo qual o acusado recebeu a pena suspensa de quatro meses de detenção, em regime aberto, tendo por objeto o delito previsto nos artigos 129, §9º e 147, caput, ambos do Código Penal (fl. 46). O trânsito em julgado do v. acórdão ocorreu em 11 de outubro de 2019, portanto, antes do fato que ora se julga. Tal condenação será tomada como reincidência, não se prestando a configurar mau antecedente para evitar dupla apenação pelo mesmo fato.

Desse modo, na primeira fase da dosimetria, atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, tendo em vista que a conduta do acusado se manteve adstrita à reprovabilidade inerente à gravidade abstrata do delito e diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, parte-se da pena de 3 (três) meses de prisão simples, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, conforme antes consignado, observa-se que se trata de indivíduo reincidente, o que conduzirá a um aumento de um sexto da pena. Ao cabo da segunda etapa da dosimetria, portanto, chega-se a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Finalmente, na terceira etapa do procedimento de individualização da pena, inexistentes causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição, torna-se definitiva a sanção 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Não estão presentes os requisitos autorizadores para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco para a suspensão condicional da pena, na forma dos artigos 44 e 77 do Código Penal, porquanto se trata de réu reincidente.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semi-aberto, uma vez que se trata de acusado reincidente, o que justifica a fixação de um regime de pena intermediário para efetiva prevenção e reparação do crime, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b" c.c artigo 59, ambos do Código Penal.

Quanto à pena pecuniária, não tendo sido demonstrada condição financeira do réu que autorizasse a majoração, cada dia-multa permanecerá em seu valor mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Por fim, decido.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido acusatório inicial para condenar o réu Adriano de Oliveira Baglivo, filho de Paschoal Rodrigues Baglivo e Bani de Oliveira Baglivo, natural de São Paulo/SP, nascido em 22 de julho de 1990, titular do documento de identidade RG n. 49278486-SP, à pena privativa de liberdade de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples e ao pagamento 11 (onze) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 50, §3º, "a", do Decreto-lei 3.688/41.

Considerando o caráter da pena imposta, não há justificativa para a custódia cautelar. Reconheço, destarte, o direito do réu de apelar em liberdade.

Determino, ademais, a destruição das máquinas apreendidas, caso tal medida ainda não tenha sido tomada. Oficie-se.

Sucumbente, o réu arcará com as custas e despesas processuais, suspensas, no entanto, devendo ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, na medida em que assistido pela Defensoria Pública (fl. 66), tendo afirmado, ademais, em interrogatório, auferir cerca de 1.200,00 (mil e duzentos) reais ao mês, atuando como servente de pedreiro.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários em favor do patrono dativo, no patamar máximo da tabela.

Ciência ao MP e à defesa (DPE).

São Paulo, 19 de abril de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA